

0001402-63.2017.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Criminal, julgado em 26/01/2017).

"Tráfico de entorpecentes - Situação de flagrante - Verificação de mensagens contidas no celular do acusado - Prova necessária ao esclarecimento dos fatos e que não se subordina aos ditames da Lei nº 9.296/96 - Nulidade inexistente - Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Denúncia anônima - Apreensão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001402-63.2017.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001402-63.2017.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial

(Flagrante) - 1134/2017 - 1º Distrito Policial de Birigui, 1134/2017 - 1º Distrito

Policial de Birigui, 230/2017 - 1º Distrito Policial de Birigui

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Mariano Baggio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 0001402-63.2017.8.26.0603 (Controle nº 1652/2017)

Vistos.

BRUNO MARIANO BAGGIO, qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data, horário e local não esclarecidos, porém no período compreendido entre os dias

02 de agosto e 11 de outubro de 2017, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular smartphone, nas cores grafite e preta, marca Samsung, modelo SMA520F/DS, IMEI 356907080226349, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e auto avaliação de fls. 42, coisa que sabia ser produto de crime.

O acusado foi solto mediante pagamento de fiança (fl. 15/16).

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 (fl. 159), o acusado foi regularmente citado (fl. 186), tendo apresentado sua defesa escrita às fls.

196/197.

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e tomados os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 219, 268/269 e 280).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 295/301).

Por outro lado, a defesa pediu a absolvição do acusado, alegando nulidade das provas colhidas, pois não houve autorização judicial para analisar o aparelho celular (fls. 304/308).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a caracterizar o delito de receptação dolosa, em sua forma simples (artigo 180, caput, do Código Penal).

De início, não há que se falar em nulidade de prova, como sustenta a defesa, em suas alegações finais.

Primeiramente, porque é de praxe que os policiais verifiquem o IMEI do aparelho para analisar se o mesmo não é produto de furto. Ademais, como se verá, um dos policiais militares disse que consultaram o IMEI pelo número atrás da bateria, sem acessar dados internos do aparelho celular, apurando ser produto de crime.

De outra parte, deve-se levar em conta que o direito ao sigilo telefônico não pode virar um salvo-conduto para a prática de crimes.

Neste sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

"[...] acerca do direito constitucional de todo indivíduo à intimidade, garantido no aspecto aqui tratado, pelo sigilo telefônico (art. 5º, XII da CF), não houve ilicitude no procedimento adotado pela autoridade policial, que, nos termos do art. 6º, incisos II e III do CPP, ao tomar conhecimento do crime, apreendeu os objetos que tiverem relação com o fato (celular dos acusados) e colheu todas as provas que serviam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (verificou que nos celulares existiam registros de mensagens relacionadas à venda de drogas). Ora, nenhum direito é absoluto, não se podendo atribuir ao indivíduo o direito de praticar crimes sem a oposição estatal. O abuso de qualquer direito o desloca ao campo da ilegalidade, não podendo se cogitar de que, sob o manto do direito à intimidade e garantia ao sigilo telefônico, se pratiquem crimes" (Apelação nº 0008243-71.2014.8.26.0153, Rel. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 06/12/2016).

"... Tampouco se cogita de ilegalidade da reprodução das mensagens recebidas pelo réu em seu telefone celular, porquanto, preso em flagrante, não havia óbice a que os policiais examinassem o aparelho então utilizado no mercadejo espúrio, conforme se constatou. Com efeito, o ordenamento pátrio não confere guarida ao exercício indiscriminado de direitos fundamentais. Nem poderia ser diferente. Afinal, o abuso termina por esbarrar na esfera de proteção jurídica de outrem" (Apelação nº 0009065-21.2014.8.26.0457, Rel. Marcelo Gordo, 13ª Câmara Criminal, julgado em 26/01/2017).

"Tráfico de entorpecentes - Situação de flagrante - Verificação de mensagens contidas no celular do acusado - Prova necessária ao esclarecimento dos fatos e que não se subordina aos ditames da Lei nº 9.296/96 - Nulidade inexistente -

Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Denúncia anônima - Apreensão de porções individuais de cocaína, maconha e lança perfume, além de dinheiro trocado - Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida - Pena e regime prisional corretos - Recurso improvido" (Apelação nº 0001565-48.2016.8.26.0063. Rel. Alexandre Almeida. 11ª Câmara Criminal, julgado em 09/05/2018)".

Anoto que, na época dos fatos, prevalecia o entendimento do julgamento do Habeas Corpus nº 91.867/PA, no qual o Supremo Tribunal Federal, em 2012, validou o acesso direto pela Polícia no celular do suspeito (STF, HC 91.867/PA, 2ª T, J. 24/04/2012):

"Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados".

Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha revisto o posicionamento adotado no referido Habeas Corpus nº 91.867/PA, entendendo ser imprescindível autorização judicial para o acesso ao aparelho, no caso dos autos, como já mencionado, foi utilizado o número do EMEI constante na parte externa do aparelho e sem acesso aos dados para se constatar a origem ilícita do celular. Ainda que assim não fosse, o certo é que o réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que forneceu, voluntariamente, a senha do aparelho celular aos policiais. Assim, nenhuma nulidade há para ser decretada, razão pela qual a preliminar fica rejeitada.

No mérito, a ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante fl. 02; os boletins de ocorrência acostados às fls. 07/10; auto de exibição e apreensão de fl. 11; a nota de culpa de fl. 17; o auto de avaliação de fls. 42; o laudo pericial de fls. 60/99; o relatório policial de fl. 36/38; as declarações da vítima; os depoimentos das testemunhas e as negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

O acusado, na delegacia, disse que foi abordado pela polícia militar, que constaram, através do IMEI, que seu aparelho celular era produto de crime. Afirmou que comprou o celular no Paraguai, há aproximadamente 08 meses, por R\$ 1.890,00 e que, quando passou pela Receita Federal, recebeu um comprovante de que havia declarado o aparelho. Disse que os policiais lhe ameaçaram para fornecer a senha do aparelho celular, se não plantariam droga para incriminá-lo. Ao final, acabou afirmando que forneceu voluntariamente a senha do aparelho celular aos policiais (fls. 05/06 e 268/269).

Como se vê, o réu negou a autoria do crime de receptação.

A negativa apresentada pelo réu não merece credibilidade, pois está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado por receptador experimentado, na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Não prospera a alegação do acusado de que teria sido coagido pelos policiais militares a fornecer a senha do aparelho celular, sob a ameaça de que iriam incriminá-lo por tráfico de drogas.

Sabe-se que os cidadãos bem-intencionados não admitem mais conviver com repressões passadas que foram sepultadas pelo Estado Democrático de Direito instalado em nosso País na atualidade.

As afirmações do réu acerca da coação por parte dos policiais ao réu são

inconsistentes e não merecem prosperar, porque, em nenhum momento, restou comprovado nos autos que os policiais tivessem algum interesse em incriminá-lo, como já acima apontado.

Ademais, como se viu, o próprio réu afirmou, ao final de seu interrogatório, que forneceu a senha voluntariamente.

Por sua vez, a vítima Maria Benta de Souza, ouvida em ambas as fases da persecução penal, disse que, no dia 03/08/2017, registrou na delegacia de Castilho/SP, o boletim de ocorrência nº 864/2017, noticiando o furto de seu aparelho celular (fl. 107, 219 e 280).

Como se vê, a vítima confirmou a ocorrência do crime anterior (furto), que ocorreu agosto de 2017, caindo por terra a alegação do réu de que havia comprado o aparelho celular no Paraguai a aproximadamente oito meses antes de ser preso em flagrante, ou seja, em fevereiro de 2017, muito antes da ocorrência do furto.

O boletim de ocorrência acostado às fls. 09/10, também comprova a origem espúria do bem.

De outra parte, as testemunhas Maurício Tesolin e , Rubens Eduardo dos Santos, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que se depararam com o acusado fazendo manobras com a motocicleta e realizaram a abordagem. Pesquisaram o IMEI do aparelho celular que estava na posse do réu e constatarem a ocorrência de furto. Relataram que não havia autorização judicial para acessar o aparelho celular, tendo o policial Rubens, em juízo, acrescentado que consultou o EMEI pelo número que constava atrás do aparelho celular (fls. 03, 04 e 268/269).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

A defesa, por sua vez, não trouxe aos autos elementos que evidenciassem interesse da vítima e das testemunhas em imputar falsamente ao acusado a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque não se apontou nada que justificasse essa circunstância.

Não se pode olvidar que o celular foi encontrado na posse do acusado e, em se tratando de receptação dolosa, caberia ao réu o ônus da prova da origem lícita do bem apreendido em sua posse.

Em outras palavras, quando o bem subtraído é encontrado em poder do agente, esse fato gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Assim, restou demonstrado que o acusado sabia da origem ilícita do bem que foi apreendido em sua posse. Aliás, o réu não apresentou o suposto documento, no qual disse que declarou o aparelho celular na aduana na fronteira com o Paraguai, providência essa que seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada, nem apresentou nota fiscal do produto, o que, somado às declarações da vítima do furto, desmentem a versão do réu de que adquiriu o aparelho naquele país.

Relevante mencionar que há certidões nos autos e o relato do réu em seu interrogatório, dando conta de que ele possui várias condenações por crimes de receptação (fls. 309/316). Na análise deste tipo penal, o fato de o agente ter a personalidade voltada à prática de delitos semelhantes, é circunstância que induz à certeza de que conhecia a origem ilícita do objeto adquirido, bem como de que agia consciente e imbuído de evidente dolo ao adquirir a coisa.

Sendo assim, o dolo específico constante do artigo 180, caput, do Código Penal, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da coisa, deve ser auferido por intermédio do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento e o exercício da posse propriamente dita.

Ressalto que o fato de a vítima ter conseguido recuperar o bem não afasta a responsabilidade penal do acusado.

Assim, além da robusta prova oral colhida na instrução, há também indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-

se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular smartphone, marca Samsung, modelo SMA520F/DS, IMEI 356907080226349, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), coisa que sabia ser produto de crime.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 180, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado possui antecedentes (fls. 309/310 - Proc. nº 0000472-45.2017.8.26.0603; fls. 310/311 - Proc. nº 0004672-87.2018.8.26.0077; fls. 311/312 - Proc. nº 0007291-24.2017.8.26.0077; e fls. 312/313 - Proc. nº 1500437-40.2019.8.26.0603), razão pela qual as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal lhe são desfavoráveis e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Torno, pois, definitiva a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Levando em conta a quantidade da pena ora aplicada e o fato de o acusado possuidor de antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, entendo que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o semiaberto.

O acusado poderá continuar a responder solto a este processo, pois assim permaneceu durante a instrução.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR BRUNO MARIANO BAGGIO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 01 (ano) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, dando-o como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o réu possui antecedentes, estando, pois, ausentes os requisitos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

O acusado poderá continuar a responder solto por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA